Droit des affaires S6

Le droit commercial

1- Le fonds de commerce :

Qu'est-ce que le fonds de commerce : Le fond de commerce est une notion juridique à peu près équivalente à la notion d'entreprise. Cette notion permet de désigner l'activité d'un commerçant (personne qui pratique une activité d'achat et de revente)

Les commerçants font une marge (ils achètent moins cher qu'ils ne revendent). La valeur ajoutée justifie la marge commerciale (en partie), souvent c'est le fait de tout proposer à un seul endroit – les sites de revente et les magasins sont des exemples de fonds de commerce

Un commerçant exploite un fonds de commerce. De la notion d'un fonds de commerce s'induit un certain nombre de prérogatives.

Un fond de commerce est un **bien meuble incorporel**.

- Un bien meuble = bien qu'on peut transporter sans en altérer la substance.

    è Il y a les meubles corporels (stylo, trousse, ordinateur, pot de fleur) – leur garantie s'appelle *gage*. Il se fait souvent (mais plus nécessairement) avec dépossession.

    è les incorporels (actions/parts sociales et fonds de commerce) – leur garantie s'appelle *nantissement*.

    è Les immeubles – leur garantie s'appelle *hypothèque*.

Le fonds de commerce est une universalité – il peut être constitué *en partie* de meubles corporels. Même dans ce cas, il est considéré comme bien incorporel.

I) Les éléments qui composent le fonds de commerce

A - La clientèle

Pas de clientèle, pas de fonds de commerce.

Qu'est-ce qu'une clientèle ?

- L'ensemble des personnes attirées par la personne, la personnalité ou le savoir-faire du commerçant.

- Achalandages : catégorie de clientèle attirée par la situation géographique du commerçant (ex : les clients des stations-services). On *peut* avoir une clientèle uniquement composée d'achalandages.

La clientèle doit être personnelle au commerçant.

24 Avril 1970 - arrêt Bayalt : Une personne exploite une buvette dans un hippodrome. Elle part à la retraite et souhaite céder ce qu'elle considère comme un fond de commerce. Hors, la clientèle qui vient à la buvette n'est pas la clientèle de la buvette mais celle de l'hippodrome. La buvette n'est donc pas un fonds de commerce mais une succursale de l'hippodrome. OU : un magasin dans centre commercial n'est considéré comme fonds de commerce que s'il peut fixer ses propre horaires et planning d'ouverture. Autrement, il n'y a qu'un fond de commerce et c'est celui du centre commercial.

L'homme qui loue les bateaux qu'on met sur le bassin du jardin du Luxembourg ne possède pas de fonds de commerce car il ne fixe ni les horaires, ni les tarifs, ni les modalités d'exploitation de son activité (et il se trouve sur le terrain du Sénat).

27 mars 2002 – arrêt Trévisan : Jurisprudence sur la **franchise** : Exploiter un fond de commerce en se servant du nom d'une marque reconnue et d'un savoir-faire. Quand on exploite un salon de coiffure Henri-David, notre clientèle est-elle la nôtre ou celle de Henri-David ? Quand on exploite un point de vente Intermarché, notre clientèle est-elle la nôtre ou celle de la marque ? Selon la jurisprudence, *il s'agit bien de la nôtre* et le franchisé a le statut de commerçant.

B- Le nom commercial et l'enseigne

L'enseigne est le nom qui identifie le point de vente. Le nom commercial est le nom sous lequel le commerçant est connu par les autres professionnel ou par les clients. Ces deux noms sont souvent identiques mais ce n'est pas obligatoire – un commerçant peut avoir plusieurs points de vente avec chacun un nom différent.

C- Le nom de domaine

Equivalent de l'enseigne pour les activités commerciales exerçant sur internet. Il se protège (il faut faire une demande de dépôt de nom de domaine en choisissant ses extensions).

D- Le droit au bail

Le droit au bail est le droit que détient le propriétaire d'un fonds de commerce - qui va conclure un contrat de bail commercial pour une durée *minimum* de 9 ans et qui bénéficie au terme de ce bail d'un droit au renouvellement du bail commercial - d'exploiter son fond dans un emplacement (qui permet d'attirer de la clientèle) pendant cette durée. Le fait de pouvoir rester dans cet endroit est un avantage, donc ce droit est un élément du fond de commerce.

E - Les licences et autorisations administratives

Pour exploiter certaines activités, il faut diverses autorisations ou licences (licence 4 pour vendre de l'alcool). Ces autorisations font partie du fonds de commerce sauf si elles sont délivrées en considération des compétences de l'exploitant.

F - Les droits de propriété intellectuelle

3 éléments principaux :

- Les brevets d'invention : protège une invention/innovation, est délivré pour 20 ans (non renouvelable). En déposer un coûte très cher.
- La marque : doit être déposé par le commerçant qui doit choisir les classes (domaines d'activités dans lesquelles il veut déposer sa marque) – protégé pour 10 ans, renouvelable.
- Dessins et modèles : Protège pour 5 ans, renouvelable 4 fois.

G - les éléments corporels

- Le matériel et l'outillage
- Les marchandises

II) Les éléments ne faisant pas partie du fonds de commerce

A - Les immeubles

Un immeuble ne fait pas partie du fonds de commerce SAUF si le commerçant vend des immeubles.

B - Les créances, les dettes et les disponibilités

Les créances et les dettes sont des engagements personnels du commerçant, tout comme ses disponibilités n'appartiennent qu'à lui. Elles ne sont pas transmises avec le fonds de commerce.

C - Les contrats

Ce sont des engagements juridiques qui n'engagent que ceux qui les ont signés, ils sont donc personnels au commerçant et ne font pas partie du fonds de commerce à 3 exceptions :

- Le bail commercial
- Les contrats de travail (art 1 224 – 1 du code du travail)
- Les contrats d'assurance

D - Les documents comptables

Ils appartiennent personnellement au commerçant et restent sa propriété s'il cède son fonds de commerce. Il doit cependant les garder à disposition de son successeur pendant au moins trois ans.

1- La cession de fonds de commerce

I) La conclusion du contrat de vente

La vente d'un fonds de commerce est avant tout un contrat. Elle doit donc respecter trois catégories de conditions :

- les **conditions générales de validité des contrats** (la capacité, le consentement libre et éclairé et l'exigence d'un objet licite et certain)
- Les conditions spécifiques aux **contrats de vente** : les parties doivent être d'accord sur la chose et sur le prix. Le prix doit être déterminé ou déterminable (doit pouvoir être fixé sans l'intervention des partis)

- De **fonds de commerce** : en 2019, l'obligation d'information spécifique sur le fonds de commerce disparaît suite à la réforme de 2016 qui institue une obligation d'information précontractuelle applicable à tous les contrats. Le fonds de commerce reste un fond complexe et il est donc nécessaire que le vendeur informe l'acheteur de manière complète sur les caractéristiques du fonds de commerce, à savoir : **Le chiffre d'affaire, le résultat, bail commercial, nantissement potentiel, nombre de salariés et caractéristiques des contrats de travail, liste des contrats existants**, entre autres… L'acquéreur ne peut bien négocier le prix que s'il a une bonne connaissance du bien.

Avant que le contrat de vente soit conclu, il faut respecter un certain nombre d'obligations pour protéger trois catégories de personnes :

- **Les communes :** loi de préemption des communes de 2005 – permet aux mairies de racheter des fonds de commerce mis en vente pour protéger le commerce de proximité. Pour pouvoir exercer ce droit, il faut que le conseil municipal définisse un périmètre de sauvegarde dans lequel elle s'en donne la possibilité. Il faut donc informer les mairies avant de conclure.

- **Les salariés** : Loi Hamon de 2014. Lorsqu'on cède un fond de commerce, il faut informer les salariés deux mois avant la signature de la vente pour que ceux-ci puissent proposer une offre de rachat alternative. Si les salariés proposent une offre, le vendeur n'est pas tenu de l'accepter. Mais si on ne respecte pas cette mesure, on se prend une amende qui peut monter jusqu'à 2% du prix de vente.

- **Les créanciers du vendeur** : La règle des délais de payement peut faire que le vendeur n'a pas fini de payer ses créanciers au moment de la cession. Pour les protéger, une procédure existe :

    - Dans les 15 jours de la vente, il faut publier une annonce dans un journal d'annonce légale.

    - Dans les 15 jours de cette annonce, il faut publier une annonce au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) – c'est le greffier du tribunal qui s'y colle.

    - A partir de la publication de cette deuxième annonce, les créanciers ont dix jours pour faire opposition au paiement du prix de vente par l'acquéreur au profit du vendeur.

    - L'argent ne va pas directement au vendeur mais va attendre sur le compte d'un « séquestre » (tierce personne professionnelle) jusqu'à la fin de ce délai d'opposition.

        - Soit il y a eu opposition : on prélève le montant nécessaire de la créance sur le prix de vente, puis on verse le reste au vendeur.

        - Soit il n'y en a pas eu : On verse le prix de vente intégralement au vendeur.

II) Les obligations des partis

A) Les obligations de l'acquéreur

- Doit exploiter le fonds

- Doit supporter tous les frais de la vente (prix de vente, publications légales, droit d'enregistrement de 3% sauf abattement)

- Possibilité d'un « crédit vendeur » : le vendeur fait la banque . L'acheteur peut payer de manière échelonnée sur plusieurs mois/années + intérêts. Si ce crédit à lieu, il existe un « **privilège de vendeur de fonds de commerce** ». C'est une garantie que le vendeur inscrit sur le fonds de commerce qui lui permet, s'il n'est pas payé, soit de demander la nullité de la vente (action résolutoire), soit d'être payé avant tous les autres créanciers de l'acheteur (droit de préférence). Si, entre-temps, l'acheteur a revendu le fonds de commerce, le vendeur à un droit de suite – c'est-à-dire de se faire payer par le sous acquéreur.

B) Les obligations du vendeur

- Obligation de délivrance : doit transmettre à l'acquéreur tous les éléments qui composent le fonds de commerce dont la clientèle.

- Obligation de garantie : le vendeur doit garantir à l'acquéreur qu'il ne sera pas empêché dans l'exploitation du fonds par le vendeur (obligation de non-concurrence)

2- La location-gérance du fonds de commerce

144 – 1 et suivant : L'ensemble des dispositions relative à la location d'un fonds de commerce sont impératives (seule la loi s'applique, les partis ne peuvent rien prévoir d'autre)

I) Les conclusion du contrat

- Il faut respecter les conditions générales de validité des contrats

- Contrat de location - Art 1713 et suivant du code civil – la personne qui loue le fonds, s'il n'a pas d'autre fonds de commerce, va pouvoir demander à se faire radier du greffe car il ne sera plus exploitant d'un fonds de commerce. Le locataire-gérant, lui, doit être

commerçant (et donc être inscrit au registre). Le contrat n'a pas à être écrit (il peut être oral) mais il vaut mieux l'écrire car la loi ne prévoit pas tout.

- Publication d'une annonce légale sous 15 jours : les créancier du loueur (proprio) peuvent demander à ce que leur créance soit immédiatement exigible. De plus, jusqu'à cette publication, le propriétaire du fonds est solidairement responsable du paiement des dettes du locataire-gérant.

II) Les effets du contrat

A) Les obligations du vendeur

- Obligation de délivrance
- Obligation de garantie

B) Les obligations du locataire

- 444 Doit faire tout ce qu'il peut pour exploiter le fonds sans le mettre en péril, ce qui se traduit lors du terme du contrat de location par l'obligation pour le locataire de payer une indemnité au loueur si la valeur du fonds a diminué.
- Payer un loyer (redevance de location gérance) soumis à la TVA.
- Doit entretenir le fonds de commerce et faire toutes les réparations d'usage.

A la fin du contrat, il faut faire une nouvelle annonce légale qui rendra immédiatement exigible des dettes du locataire gérant.

Cours 4 Le nantissement du fond de commerce

C'est une garantie que propriétaire a sur un fond de commerce par rapport aux garanties personnelles qui portent sur tous les biens d'une personne
Garantie du fond de commerce demandée par les banques (mais elles ne vont pas forcément donner un prêt), pour garantir une obligation du fond de paiement).
Garantie utile mais incertaine, dangereuse: lorsque le commerçant met en place le nantissement du fond de commerce il garantit le paiement du fond par un commerçant. Le commerçant gagne de l'argent par le fond de commerce mais lorsque la valeur du fond de commerce baisse (le Chiffre d'Affaire baisse). La valeur de garantie baisse.
La mesure pour faire vendre le fond de commerce est la valeur basse du fond de commerce.

Si le fond de commerce est en difficulté-> CA baisse-> valeur du fond de commerce baisse.

Donc donner un nantissement sur un fond de commerce est une garantie dangereuse. Il vaut mieux prendre différentes garanties, de cette façon la valeur du patrimoine peut être plus élevée

Si la situation du commerçant est difficile c'est à cause de la baisse de la valeur du fond de commerce.

Le nantissement peut fournir une contrepartie financière

1. Les formes du nantissement

A) Nantissement conventionnel

Le nantissement conventionnel c'est un contrat conclu entre le créancier et le commerçant. Ce contrat est obligatoirement écrit. Peut être sous seing privé (contrat classique) ou par acte authentique devant un notaire. (contrat synallagmatique: contrat entre deux personnes réciproque). Présence d'une assiette du nantissement: éléments sur lesquels repose le fond de commerce. La loi donne une assiette maximale, à l'article L182 du code du commerce, ce sont tous les éléments du fond de commerce (expliqué au premier cours).
La clientèle et l'achalandage fait partie de cette assiette, si ces éléments ne font pas partie de l'assiette pas de nantissement. Si l'assiette du nantissement n'est pas prévu dans le contrat alors la loi aide en prévoyant une liste à minima qui inclut des éléments dans le nantissement conventionnel: clientèle ou achalandage, droit au bail, enseigne et nom commercial.

Le contrat de nantissement est signé et enregistré à la date des impôts, "donner date certaine au droit": ne pas pouvoir contester. Il faut également enregistrer ce nantissement au greffe du tribunal du commerce, remplir un bordereau.

Un nantissement dure 10 ans à partir de son inscription au tribunal du greffe de commerce, il peut être renouvelé en rédigeant un avenant au contrat initial et que cet avenant soit conclu avant le terme des 10 ans. L'enregistrement du contrat au greffe doit être pris dans les 15 jours de la signature.

Il existe des cas où le commerçant s'oppose au nantissement, il faut alors remplir des procédures: le nantissement judiciaire

B) Nantissement judiciaire

Le contrat possède ou non un titre exécutoire. Soit un acte authentique passé devant un notaire (contrat notarié), soit une décision de justice définitive qui n'est plus susceptible d'aucun recours, un mois pour faire appel si montant minimum disponible pour faire appel: un arrêt qui a été formulé sans pourvoi de cassation.
Si créancier dispose d'un titre exécutoire: un titre pouvant être ~validé par un tribunal. Possibilité de voir le tribunal de commerce
Si le créancier n'a pas de titre authentique ou pas de suite judiciaire. Le créancier devra respecter deux étapes fondamentales sans lesquelles il ne peut pas inscrire son nantissement:
Étape 1: le créancier doit obtenir un titre provisoire pour inscrire son nantissement, c'est le nantissement conservatoire. Pour l'obtenir il doit aller voir le juge, procédure très courte

puisqu'il le saisit sur requête (=pas de procédure contradictoire). Première condition. Ce juge accorde le nantissement si deux critères sont remplis: la créance doit paraître fondée dans son principe. Le juge pense que la créance est fondée. Deuxième critère: il doit exister des critères susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. L'autorisation n'est que provisoire. La mesure provisoire protège les créanciers sans mesure exécutoire. Après le juge saisi par requête, le créancier repart avec une ordonnance (obtenu très facilement). Puis il inscrit le nantissement au greffe au tribunal de commerce, le faire dans le mois qui suit l'ordonnance
Étape 2: Comme ce n'est que provisoire, soit passer par le notaire ou tribunal de commerce, pour obtenir un jugement qui condamne le commerçant d'une dette de commerçant. Un an pour saisir le tribunal: pendant ce temps d'autres créanciers peuvent inscrire leur nantissement sur le même fond de commerce. Ces créanciers peuvent passer devant le tribunal. L'ordonnance neutralise l'inscription postérieure du tribunal de commerce. Le titre exécutoire va rétroagir sur la date du nantissement provisoire. Dernière inscription: le nantissement définitif après des années rétroagira au nantissement provisoire

2. Les effets du nantissement

Le nantissement n'emporte pas des décisions sur le fond de commerce. Il ne peut pas retirer le fond de commerce au commerçant. Toutefois le nantissement permet au créancier permet d'obtenir: A) le droit de préférence

A) le droit de préférence

Permet au créancier bénéficiant d'un autre nantissement d'être payé avant les autres créanciers qui n'ont pas de garantie: les créanciers chirographaires.
Le créancier nanti ne passera jamais devant le privilège du vendeur de fond de commerce: il passera toujours devant tous créanciers, même si le privilège est inscrit après le nantissement .

B) le droit de suite

Si un créancier a inscrit son nantissement et que le fonds est vendu il pourra être payé auprès du nouveau propriétaire du fond de commerce.

C) des garanties spécifiques

Ces garanties sont accordées lorsque certains événements affectent le fond de commerce. Comme lorsqu'il y a déplacement du nantissement auprès d'un autre greffe ou lorsqu'il y a résiliation du bail commercial ou déspécialisation de l'activité du fond de commerce. Dans ces trois cas le bénéficiaire du nantissement doit être averti pour pouvoir sauvegarder ses droits: l'un des ou dans la phrase plutôt

Cours 5 le bail commercial

Le statut des baux commerciaux a pour but de protéger le commerçant qui loue un local. Intérêt pour le commerce moderne. L'emplacement du local joue un rôle important, de cet emplacement dépend la fréquentation et de la valeur du chiffre d'affaire.
La principale caractéristique des baux commerciaux est la durée minimum de 9 ans et une durée maximale inférieure à 18 ans (17 ans, 11 mois et 13 jours). Au-delà , ce sont les baux emphytéotiques. Le droit au renouvellement des bails commerciaux est inscrit dans les statuts.

A) les champs d'applications des statuts des baux commerciaux

D'après l'article L145 et suivants. Ce statut s'applique à certaines conditions: à un local dans lequel un fond est exploité. Ce statut ne s'applique pas aux comptoirs de ventes dans les galeries commerciales. Ne s'applique pas non plus dans les terrains sans local: terrain nu. Les statuts des baux commerciaux ne bénéficient qu'aux commerciaux qui sont inscrits au registre des baux commerciaux.

Limite pour les beaux qui ne vont que jusqu'à 99 ans, se distingue du bail précaire-convention d'occupation précaire. Bail conclu dans l'attente d'un événement incertain qui affecte le local (ex. on sait que le local sera détruit mais on ne sait pas quand il sera détruit. Si c'est jusqu'à 6 mois on peut mettre en place une condition précaire jusqu'à 6 mois. Distingue les bails commerciaux également les bails de courte durée: contrats de locations avec durée inférieure à trois ans.

Contrats de baux commerciaux se distingue des contrats de domiciliation: empêcher les commerçants d'avoir des adresses soit qui ne correspond pas au lieu d'exploitation définitive, soit une adresse pour une activité qui n'a pas besoin d'un local permanent

B) le contenu des statuts des baux commerciaux

1. l'état des lieux

   Lorsqu' est conclu un contrat de bail commercial, il faut faire un état des lieux lorsque le locataire commence vraiment à exploiter les lieux. Idéalement, cet état des lieux doit être établi par un commissaire de justice=huissiers de justices, les frais de ces derniers sont répartis entre le bailleur et le locataire. Il faut établir un même état des lieux lors de la cessation des bails commerciaux

1- La durée du bail

9 ans minimum (pour protéger le locataire qui va investir pour aménager les locaux) afin d'amortir cet investissement. Le bailleur ne peut pas mettre fin au bail en avance SAUF :

- Faute commise par le locataire (il ne respecte pas un des articles du bail commercial-ex : loyer impayé) – Le loueur saisit alors le juge en visant l'acquisition de la clause résolutoire.

- En cas de reconstruction/restauration/surélévation de l'immeuble où se trouve le local, une fois tous les trois ans après avoir conclus le bail et avec un préavis minimum de 6 mois et un **congé** (décision de rupture du bail).

Le locataire peut mettre fin au bail tous les trois ans. S'il le fait avant, il devra continuer a payer le loyer jusqu'à la fin de cette période. (TOUS les trois ans – si on part au bout de quatre, il faut payer le loyer jusqu'à ce qu'on ait atteint les 6)

- Bail portant sur des locaux exclusivement composés de bureaux
- Bail conclus pour une durée de plus de 9 ans.

2- La déspécialisation

La modification de l'activité exercée par le commerçant dans le locaux loués.

Si le commerçant ajoute à son activité une seconde qui à un lien avec la première (bijoutier qui décide de vendre aussi des montres ou un boulanger qui veut aussi faire de la pâtisserie), c'est de la **déspécialisation partielle** et c'est possible sans autorisation du bailleur. Ça vaut même si la nouvelle activité devient plus importante que la première.

Si le commerçant remplace son activité par une autre, c'est une **déspécialisation totale** et il faut obtenir l'autorisation du bailleur. S'il refuse, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire qui, souvent, autorise cette transition à condition qu'elle n'entraine pas de préjudice pour le bailleur.

Dans les contrats de bail, on prévoit la palette d'activité que le locataire peut exercer dans le local. Il est possible d'autoriser n'importe quelle activité, et dans ce cas, il n'y a pas de déspécialisation.

3- Les travaux

Il faut décider à l'avance dans quelle mesure quelles charges reviennent à qui. En général, le locataire doit prendre en charge les restaurations usuelles et le propriétaire, les grosses réparations (les murs et le toit).

Cette répartition ne couvre pas tous les cas et il y a régulièrement des litiges assez complexes à statuer.

4- Les charges locatives

La loi Pinelle de 2014 a précisé de quelles charges locatives et impôts on pouvait demander le remboursement au locataire. Ex – la taxe foncière. Elle doit être payée par le propriétaire mais peut être remboursée par le locataire (uniquement pour les baux commerciaux, pas d'habitation).

Le bailleur doit fournir chaque année au locateur une liste prévisionnelle des travaux qu'il compte effectuer au cours des trois années suivantes.

5- Le droit au renouvellement du bail commercial

Droit spécifique au commerçant, droit d'obtenir le renouvellement du bail à son terme.

Trois hypothèses :

- Le bailleur propose au locataire le renouvellement du bail. Cela doit faire l'objet d'un **congé avec offre de renouvellement**. Délivré par un huissier/commissaire de justice au plus tard 6 mois avant la fin du bail.

    è Si le bailleur délivre un congé sans offre de renouvellement, et à moins que ce soit la conséquence d'une faute du locataire, le bailleurs devra au locataire une **indemnité d'éviction** qui a pour but de compenser le préjudice que subit le locataire en raison du fait qu'il devra déménager son fonds de commerce dans un autre local (frais de déménagement, d'agence et de rénovation du nouveau local, perte de clientèle/de valeur du fonds).

- Le bailleur ne délivre pas de congé à temps. Le locataire peut alors demander le renouvellement du bail pendant les 6 derniers mois.

- Si au terme du bail, personne n'a rien fait ni délivré, le bail se poursuit pour une **durée indéterminée** ce qui veut dire que chaque partie peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de 6 mois (en théorie, il prend fin au terme du trimestre civil en cours)

Mécanisme du plafonnement :

- Le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative (prix du marché).

- L'augmentation du loyer ne peut pas dépasser l'évolution de l'indice IMC depuis la conclusion du bail.

Ces deux règles doivent se combiner. Soit la valeur locative est inférieure au plafond, on retient la valeur locative. Si elle est supérieure au plafond, on retient le plafond SAUF en cas de modification des **facteurs locaux de commercialité** (s'il y a eu une modification de

l'environnement du local ayant entraîné une hausse de la valeur locative supérieure à 10%). Dans ce cas, on retient la valeur locative.

6- Le droit de préférence en cas de vente du local

Lorsque le propriétaire souhaite vendre le local, il doit impérativement proposer au locataire de l'acheter avant de le vendre à un tiers. Il doit envoyer une lettre de recommandation avec accusé de réception au locataire et celui-ci a un mois à compter de la réception pour répondre. Si la réponse est positive, la vente doit se conclure dans les deux mois après la réponse, quatre si le locataire sollicite un crédit auprès d'une banque.

B- La protection des intérêts du bailleur

1- La cession du bail et la sous-location

Lorsque le contrat de bail est cédé hors du cadre d'une cession de fonds de commerce ou quand le locataire envisage de sous louer le local, l'autorisation du bailleur est obligatoire et doit être constatée dans le contrat de cession/sous-location sous peine de nullité.

Si le bail est transmis dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, sa transmission est automatique et le bailleur ne peut pas s'y opposer.

En cas de fusion de la société locataire ou de TUP, le bail est transmis sans que le bailleur puisse s'y opposer.

2- L'évolution du loyer pendant l'évolution du bail

1-

L'évolution du loyer suit la règle de l'indexation – une évolution du loyer pendant le bail par rapport à n indice. Cette évolution est triennale et calculée sur la base de l'INC (Indice des Loyers Commerciaux). Ou de l'ILAT (Indice des loyers des activités tertiaires)

Cette indexation est d'ordre publique (donc de droit) mais n'est applicable que si l'une des partie le demande. Il est très rare qu'elle soit appliquée car elle est souvent remplacée par une indexation conventionnelle, en général annuelle, toujours sur la base du même indice, et qui s'applique automatiquement.

L'indice ne sert pas de plafond mais bien d'indice –

Il peut arriver que le loyer soit, en partie ou en totalité, un pourcentage du chiffre d'affaire. C'est la **clause recette**. Dans ce cas, l'indexation n'est pas applicable, sauf éventuellement à la partie stable.

Cours 6 : La conclusion du contrat commercial

1- Les négociations contractuelles

En octobre 2016, une nouvelle ordonnance entre en application. Avant ses règles, il n'existait pas d'obligation d'information lorsqu'on négocie.

A) Obligation précontractuelle d'information

Art 112 – 1 : La partie qui a connaissance d'une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie doit lui transmettre cette information dès lors que légitimement, cette partie l'ignore. Cette information doit avoir un lien direct avec le contenu du contrat ou les qualités des parties.

Elle doit être transmise de manière spontanée par la partie qui en a connaissance.

Cette obligation vaut pour tous les contrats, civils ou commerciaux. La liste des informations varie sensiblement en fonction du contrat.

1989 – loi Doubin : le franchiseur doit transmettre au futur franchisé toutes les informations relatives au fonds de commerce 20 jours avant la conclusion du contrat.

B) Obligation de confidentialité

La loi pose un principe général applicable lors de toute négociation précontractuelle : Les négociateurs doivent garder une confidentialité totale sur les information qu'elles s'échangent lors de ces négociations contractuelles.

En pratique, cette obligation ne change pas grand-chose car avant, les parties signaient un contrat de confidentialité et ça se fait toujours.

En effet, cette obligation est intéressante mais elle a un problème : elle ne précise pas les infos concernées, les parties, ni la durée pour laquelle elle est applicable. De plus, celui qui brise un contrat (de confidentialité) engage sa responsabilité contractuelle. Il est donc plus facile de saisir le tribunal.

Sinon il faut :

- Prouver qu'une partie a commis une faute

- Prouver l'existence d'un préjudice

- Prouver l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

C'est aussi pour cette raison qu'on ne laisse jamais la loi seule sans la préciser d'un contrat.

C) Rupture des négociations précontractuelles

En négociation, on doit toujours être de bonne foi - Art 1 104 du code civil, rang de règle d'ordre public.

Cette obligation n'empêche pas de mettre fin à des négociations mais de les rompre n'importe comment et n'importe quand. Il y a faute (et donc abus) si une partie, alors qu'on est à un stade avancé des négociations, laisse croire à l'autre que le contrat sera signé puis se désiste brutalement.

→ quel montant pour le préjudice ? Le préjudice subi par la partie victime sont les coûts engagés par la partie pour les besoins de la conduite de ces négociations. C'est tout.

2- La formation du contrat

A) La capacité

La capacité des parties – voire cours 1 et 2 du semestre 5.

B) L'offre et l'acceptation

La loi ne prévoit rien, les règles ont été posées par les juges.

Lorsqu'une partie fait une offre de conclure un contrat. Elle doit satisfaire deux conditions : être précise (contenir les éléments essentiels du futur contrat, la chose, le prix, ect…) et ferme (la seule acceptation des éléments contenus dans l'offre doit permettre la conclusion du contrat).

Si le destinataire de l'offre la modifie, alors il exprime à son tour une offre qui doit être acceptée par l'auteur initial de l'offre.

Si elle ne comporte pas de délai explicite, l'offre est valable pendant une 'durée raisonnable' laissée à l'appréciation du juge.

L'acceptation est libre (même s'il est conseillé qu'elle soit écrite) – une exécution sans acceptation explicite peut être considérée comme une acceptation en soi.

Si le destinataire ne répond rien, cela compte comme un refus. SAUF :

- S'il existe un courant d'affaire antérieur (entre commerçants) portant sur le même type de contrat.
- S'il existe des usages applicables dans certaines professions qui prévoient l'inverse (ex : pour les banques)
- Si l'offre est fait dans l'intérêt exclusif de son destinataire

C) La validité du consentement

Trois vices : Le Dol, l'erreur et la violence

Sanction : une nullité relative – elle ne peut être invoquée que par la victime du vice de consentement. Le délai de prescription est de 5 ans. Cette nullité a un effet rétroactif ; elle annule tout ce qui a été fait par les parties pour les remettre dans la situation où ils était avant le contrat

D) L'exigence d'un contenu licite et certain

3- La signature du contrat

A) La notion de représentant légal

Les sociétés sont représentées par leurs dirigeants (les dirigeants auxquels la loi attribue le pouvoir de représenter le société vis-à-vis des tiers). Si une personne autre que celles-ci signe, la société n'est pas engagée mais dans certains cas, les tiers, pour se protéger, peuvent invoquer la théorie de l'apparence.

Si la personne se présente comme ayant le pouvoir de contracter, ce contrat pourra être déclaré valable par le juge mais la personne ayant signé sans en avoir le pouvoir engage sa responsabilité. Si c'est un salarié, c'est un motif valable de licenciement.